

1503104-04.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503104-04.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503104-04.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2263933/2021 - DISE-DEL.SEC.LIMEIRA, 20509467 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 147/21/819 - DISE-DEL.SEC.LIMEIRA, 2263933 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GRACYELLA AYEL DE PAULA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

GRACYELLA AYEL DE PAULA, qualificada nos autos, está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta do incluso inquérito policial que, em 27 de setembro de 2021, por volta das 15h45min, na Rua João Ari Cason, 87, Jardim Gustavo Peccinini, nesta cidade e comarca de Limeira, a acusada, em atividade de tráfico ilícito de entorpecentes, trazia consigo, para serem entregues ao consumo de terceiros, 03 (três) porções de cocaína, pesando cerca de 03, e 01 (uma) porção de "Cannabis Sativa L.", popularmente conhecida como maconha, com peso aproximado de 5,2g, bem como guardava e tinha em depósito, com a mesma finalidade, 09 (nove) porções de maconha, pesando cerca de 40,5 g, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar conforme auto de exibição e apreensão de e laudo de exame toxicológico. Na data dos fatos, a denunciada se encontrava na via pública com

drogas, para consumo de terceiros.

Segundo apurado, no dia dos fatos, a denunciada trazia consigo, guardava e tinha em depósito as sobreditas substâncias para fins de comercialização.

Ocorre que policiais civis realizavam diligências pelo sítio do evento, já conhecido como ponto de tráfico ilícito de entorpecentes, quando avistaram a denunciada juntamente com três indivíduos não identificados nos autos, em atitudes atinentes a emergir suspeitas.

Realizada abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os três indivíduos. No entanto, com a denunciada foram encontradas 03 (três) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, drogas que trazia consigo para serem entregues ao consumo de terceiros, bem como a quantia de R\$61,60 (sessenta e um reais e sessenta centavos), oriundo do narcotráfico.

Em seguida, realizada vistoria nas imediações, os agentes públicos localizaram, próximo ao local da abordagem e sobre um muro, outras 09 (nove) porções de maconha, drogas que a denunciado ali guardava e tinha em depósito também para serem destinadas ao narcotráfico.

Na esfera policial, GRACYELLA confirmou a prática da mercancia ilícita

Oferecida a denúncia, determinou-se a notificação da acusada para que apresentasse defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 111/112).

A denúncia foi recebida em 26 de abril de 2022 (fls. 113/114).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e a ré, interrogada ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

O Ministério Público e a Defensoria Pública ofertaram memoriais orais.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A preliminar de prova ilícita em razão da ilegalidade da busca pessoal será analisada em conjunto com o mérito da ação penal.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 15/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), laudo pericial com resultado positivo para "cocaína e maconha" (fls. 29/32 e 79/81), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Em Juízo, a ré disse que tem 19 anos. Trabalha como faxineira. Realmente cometeu o delito. Já havia sido encerrado o plantão. Repassou o dinheiro das vendas. Foi um momento de fraqueza. Ficou internada em clínica. Agiu por necessidade. O que estava na bolsa era sobre o lucro. Não é dona do que estava no muro (mídia).

Vejamos o teor da prova oral, em harmonia com a confissão judicial.

A policial civil Jane Aparecida da Costa disse que o local da abordagem é muito

conhecido nos meios policiais pela traficância. No dia em questão estava com outros policiais. Viram a ré na esquina com mais três rapazes. Ela estava com uma bolsa e havia 3 pinos de cocaína, uma porção de maconha e dinheiro em seu poder. Ela assumiu a droga e disse que repassou o dinheiro de um kit, na parte da manhã ela já esteve no local efetuando a venda de drogas. Porções de maconha foram encontradas há cerca de quinze metros, mas ela negou ser dona. Ela confirmou a venda de kits naquele mesmo dia, com a entrega de dinheiro, aquilo ali era o lucro dela. Não a conhecia até então (mídia).

O policial civil Tiago Andrade Pucci disse que se recorda dos fatos. Faziam diligências pelo bairro, é local muito conhecido pela traficância ilícita. Estava com outros policiais. Viram a acusada e mais três rapazes em atitude suspeita. Nada encontrou com os rapazes. Em poder dela a policial Jane achou drogas e dinheiro. Encontrou porções de maconha em cima do muro, iguais as que estavam no bolso. Ela assumiu a venda de drogas (mídia).

Ressalto que o depoimento de policiais civis neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos policiais, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente o réu.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Pelo teor da prova oral colhida, policiais civis realizam diligências pelo sitio do evento, quando avistaram a acusada juntamente com três indivíduos não identificados.

Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os três indivíduos. No entanto, com a ré foram encontradas 03 (três) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, bem como a quantia de R\$ 61,60 (sessenta e um reais e sessenta centavos), oriundos do tráfico de entorpecentes.

Em diligências nas imediações, os agentes públicos localizaram, próximo ao local da abordagem, 09 (nove) porções de maconha, drogas que a ré guardava e tinha em depósito. A ré foi presa em flagrante delito.

Dessa forma, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico, haja vista a quantidade, natureza, diversidade e a forma como estavam embaladas as drogas (cocaína e maconha), a conduta da acusada quando da prisão, as circunstâncias e o local da abordagem, além da confissão judicial, tudo a apontar a ré como pessoa envolvida no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Ausência de visualização de atos de mercancia - Irrelevância - Tipo misto ou de conteúdo variado - Condenação mantida (...) ". (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)". (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

Note-se, ainda, que a acusada nada indicou de real para colocar dúvidas sobre a atuação dos policiais civis, pois eles sequer conheciam a acusada e a abordagem foi de rotina.

É inquestionável que a ação da Polícia Civil se revestiu de fundada suspeita, em conformidade com o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, sendo descabida a aventada ilegalidade da busca pessoal.

Durante o patrulhamento rotineiro, a acusada foi abordada após demonstrar nervosismo em via pública, em local conhecido pela traficância ilícita, ao lado de outras pessoas de reputação duvidosa, que resultou no encontro de drogas e dinheiro, havendo confissão informal aos policiais civis e em solo judicial, circunstâncias estas que somadas geraram a fundada suspeita da posse de objetos ou substâncias ilícitas, que, por sua vez, autorizaram a busca em conformidade com os artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal.

Nessa direção, confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. (...) 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (...)" 6. Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no HC 685.437/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Hipótese em que o Tribunal de origem, diante das circunstâncias peculiares do caso - veículo parado em atitude suspeita, durante a madrugada, com quatro indivíduos em seu interior - entendeu haver fundada suspeita para a realização da abordagem pessoal, que resultou na apreensão de arma de fogo. A decisão vergastada está em consonância com o art. 244 do CPP e os elementos fáticos consignados no acórdão recorrido são legítimos para fins de busca pessoal. Rever a conclusão do aresto necessitaria do reexame do conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1403409/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 04/04/2019).

Não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consuma.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

"(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece

inviabilizar a tentativa (...)” (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Ainda, não há que se falar em princípio da insignificância, pois o entorpecente, mesmo em pouca quantidade, pode causar danos à saúde pública (bem jurídico protegido pelo tipo penal incriminador).

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra a acusada, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Concernente ao crime de tráfico de drogas, as circunstâncias judiciais dos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/2006, são inteiramente favoráveis a ré, devendo a pena-base partir do mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes. Por outro lado, deixo de aplicar qualquer atenuante, pois a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo, observando-se o teor da Súmula n. 231 do Colendo STJ.

Ausentes quaisquer causas de aumento.

Sendo a ré primária, de bons antecedentes, confessa e não havendo prova de que integra organização criminosa, aplico a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4ª, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a reprimenda em 2/3 (dois terços), tornando-se definitiva a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Na falta de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do delito, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, para afastar a aplicação da minorante quando evidenciarem a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes (cf. STJ, HC 481.527/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019).

Para que fique bem claro, na derradeira etapa do sistema trifásico, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada.

A este respeito, deve ser acolhido o seguinte preceito doutrinário:

“Dispõe o parágrafo, em sua parte final, sobre condições negativas de que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Toda prova negativa é difícil, de modo que militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, no caso, é do Ministério Público no sentido de demonstrar a reincidência, os maus antecedentes e a participação em atividades criminosas ou organização criminosa. Não importa que a prova seja difícil para o Ministério Público. Mais difícil seria para o réu que, por sua vez, tem o direito de não ser condenado a não ser que haja prova, ou receber, sem prova, uma pena maior quando a lei permite uma pena mais branda” (GRECO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel. Lei de Drogas Anotada. São Paulo: Saraiva, 2008).

O valor do dia multa será fixado no mínimo legal.

Considerando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no acórdão proferido no

HC 118.553/MS, no sentido de que o delito de tráfico de drogas privilegiado não possui natureza hedionda, revejo meu entendimento para admitir à fixação de regime inicial carcerário mais brando aos condenados pela prática daquela infração penal.

De fato, o tráfico de entorpecentes privilegiado não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos.

A obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e aos a eles equiparados não mais subsiste, diante da declaração de inconstitucionalidade, "incidenter tantum", do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, pelo STF, no julgamento do HC 111.840/ES.

Dessa forma, fixo o regime inicial aberto para o caso em questão.

Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, conforme Súmulas 440/STJ e 718 e 719 do Colendo STF, o que não se viu no caso em tela.

No mais, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, aplica-se a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) na fixação do regime prisional, assim como as decisões dos Tribunais Superiores (STF e STJ).

Ante a quantidade da pena imposta, a primariedade, a confissão e tendo em vista a decisão do STF no sentido de que o tráfico privilegiado não pode ser considerado como crime hediondo, além da natureza e quantidade de entorpecente localizada, estando presentes os requisitos que autorizam a medida, substituto a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser definida em sede de execução criminal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar GRACYELLA AYEL DE PAULA, qualificada nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no seu menor valor, como incursa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c a redução prevista no §4º do art. 33 ambos da mesma lei.

Diante do quantum fixado, poderá a ré recorrer em liberdade.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos acima fundamentados.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora concedida.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida, com as cautelas de praxe, pela qual representou a autoridade policial.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido.

Após o trânsito em julgado, o nome da ré deverá ser lançado no rol dos culpados.

Publicado em audiência, saem os presentes intimados.

Limeira, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA